

1501066-44.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... arquivos com conteúdo referente ao tráfico de drogas nem comunicações através de aplicativos ou informações de geolocalização (fls. 178/181).

A testemunha Investigador de Polícia Sérgio Nunes Pombo Filho relatou que o Setor de Inteligência da Polícia Civil fez investigações e apurou que havia alguns pontos de tráfico na cidade de Adolfo. Declarou que, com base em tais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501066-44.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501066-44.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170485/2022 - DEL.POL.ADOLFO, 25727949 - DEL.POL.ADOLFO, 2170485 - DEL.POL.ADOLFO

Autor:

Justiça Pública

Réu

CRISTIANO MARQUES DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

CRISTIANO MARQUES DE LIMA (fls. 36/37) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 79/82).

Isso porque, segundo consta, em 23 de junho de 2022, às 06h35, na Rua Manoel Carlos Figueiredo Ferraz, frente e fundos, nº 301, centro, cidade de Adolfo-SP, comarca de José Bonifácio-SP, o acusado praticou o ato de ter em depósito e guardar, para entrega a consumo de terceiros, 184 invólucros contendo cocaína, na forma de crack, pesando 13,55 gramas; 01 invólucro contendo maconha, pesando 2,44 gramas; 37 invólucros plásticos, contendo cocaína, na forma de crack, pesando 4,09 gramas e, 21 invólucros plásticos, contendo cocaína, na forma de crack, pesando 1,05 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: Investigador de Polícia Sérgio Nunes Pombo Filho (fl. 3), PM José Renato Cabral (fl. 4), Tyrone Henrique Santos (fl. 5) e Gabriel dos Santos Matos (fl. 6).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 61/62).

Recebida a denúncia (fls. 112/114), o acusado foi notificado (fl. 92), citado

pessoalmente (fl. 133) e apresentou defesa prévia (fl. 108), por defensor nomeado (fl. 104), negando a prática do delito e pedindo absolvição, sem arrolar testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu o reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 11/16), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 3/6 e 9), auto de apreensão e entrega (fls. 19/20), fotografia (fl. 38), relatório final (fls. 99/102) e laudos periciais (fls. 24/24; 93/95 e 116/118) .

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Segundo se apurou, em circunstâncias que serão melhor aclaradas na instrução criminal, o denunciado obteve a substância ilícita acima mencionada e passou a guardá-la, com o fim de comercializá-la.

Na data dos fatos, durante cumprimento demandados de busca e apreensão expedidos nos autos do processo nº 1500584-79.2022.8.26.0306, policiais civis e militares dirigiram-se até o local dos fatos, residência de CRISTIANO MARQUES DE LIMA ocasião que, em vistoria realizada na residência dos fundos do local, foram localizadas e apreendidas, no sofá, dentro de um pote, junto a CRISTIANO 37 porções de crack. Ainda, no quarto onde estavam os adolescentes TYRONE HENRIQUE SANTOS e GABRIEL DOS SANTOS MATOS, os policiais localizaram e apreenderam 184 invólucros contendo cocaína, na forma de crack, pesando 13,55 gramas; 01 invólucro contendo maconha, pesando 2,44 gramas.

Ainda, com GABRIEL encontraram e apreenderam R\$60,00 em notas diversas e, com TYRONE encontraram e apreenderam R\$ 707,45, em notas e moedas diversas. Por fim, na residência da frente do referido endereço, foram localizados e apreendidos 21 invólucros plásticos, contendo cocaína, na forma de crack, pesando 1,05 gramas. Ainda, localizaram e apreenderam dois aparelhos de telefonia celular, pertencentes ao denunciado e, um aparelho celular pertencente ao adolescente GABRIEL e, 12 sacos plásticos. Auto de exibição e apreensão acostado às fls. 19/20.

A quantidade, o modo de acondicionamento da droga apreendida, bem assim as condições em que se desenvolvia a ação criminoso e as circunstâncias da prisão revelam o inequívoco intuito de tráfico de drogas pelo denunciado, bem como que sua prática envolveu os adolescentes TYRONE HENRIQUE SANTOS e GABRIEL DOS SANTOS MATOS. Laudo de constatação (fls. 24/28), detectou no 01 invólucro contendo maconha, pesando 2,44 gramas apreendido no quarto, junto aos adolescentes, a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); nos 184 invólucros contendo cocaína, na forma de crack, pesando 13,55 gramas constatou-se a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); nos 21 invólucros plásticos, contendo cocaína, na forma de crack, pesando 1,05 gramas, foi constatada a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e, nos 37 invólucros plásticos, contendo cocaína, na forma de crack, pesando 4,09 gramas a presença da substância, foi detectada a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Foram apreendidos:

- Em poder de Cristiano: um aparelho celular com tela danificada da marca Huawei; um aparelho celular rosa com tela danificada da marca Multilaser; aproximadamente 12 sacos plásticos pretos, brancos, alaranjados e transparentes, rasgados, utilizados como embalagens; 37 invólucros com pedras de crack (lacre nº 0022413 -

não pesados por não possuir balança oficial na delegacia); 21 invólucros com pedras de crack (lacre nº 0022451 - não pesados por não possuir balança oficial na delegacia);

- em poder de Gabriel: um aparelho celular preto da marca Samsung; a importância total de R\$ 60,00 em dinheiro, sendo 05 cédulas de R\$ 10,00 e 02 cédulas de R\$ 5,00; 1 invólucro de maconha (lacre nº 002242 - não pesado por não possuir balança oficial na delegacia);

- em poder de Tyrone: a importância total de R\$ 707,45 em dinheiro, sendo 02 cédulas de R\$ 100,00, 03 cédulas de R\$ 50,00, 12 cédulas de R\$ 20,00, 07 cédulas de R\$ 10,00, 05 cédulas de R\$ 5,00, 05 cédulas de R\$ 2,00 e R\$ 12,45 em moedas; 184 invólucros com pedras de crack (lacre nº 0022453 - não pesados por não possuir balança oficial na delegacia).

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para:

1- cocaína nas amostras colhidas de 184 invólucros plásticos fechados por aquecimento, sendo 56 de cor branca e 128 de cores transparente (externo) e verde (interno), todos encerrando porção de material sólido petrificado de cor bege com massa líquida de 13,55 grama(s). Também havia 01 frasco plástico de cor preta fechado por tampa própria de rosquear, aparentemente vazio, contendo rótulo com inscrições: "godvit" "acetilcisteína 20mg/ml" "contém 120ml" "suplemento alimentar em solução oral", de dimensões máximas aproximadas de 10,5cm de altura x 4,8cm de diâmetro da base (lacre 0022453);

2- tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de um invólucro plástico transparente, aberto, encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com massa líquida de 2,44 grama(s) (lacre 0022452);

3- cocaína nas amostras colhidas de 37 invólucros plásticos fechados por aquecimento, sendo 36 de cor branca e 01 de cor vermelha. Destes, 36 invólucros encerravam porção de material sólido petrificado de cor bege com massa líquida de 4,02 grama(s) e, no momento do exame, em 01 dos invólucros plásticos de cor branca foi observada a presença de um material sólido petrificado de cor cinza, com massa líquida de 0,07 grama(s). Também havia 01 frasco plástico transparente, fechado por tampa própria de rosquear de cor branca, aparentemente vazio e desprovido de invólucro de altura aproximada de 9,1 cm com fundo parcialmente rachado (lacre 0022413);

4- cocaína nas amostras colhidas de 21 invólucros plásticos fechados por aquecimento, de cores branca (externo) e azul (interno), todos encerrando porção de material sólido petrificado de cor bege, parcialmente azulada possivelmente devido à impregnação de tinta do invólucro interno, com massa líquida de 1,05 grama(s).

O laudo de exame químico-toxicológico que analisou a sacola de cor preta, com cerca de 40 centímetros de comprimento e 19 de largura, encerrando diversos fragmentos de plásticos de tamanhos, cores e formatos variados, contendo resquícios e sujidades apontou resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol - THC com massa bruta de 15,24 grama(s) (lacre 0022464).

A perícia no aparelho celular da marca Multilaser localizou diversas fotos relacionadas a entorpecentes e armas, além de conversas no aplicativo WhatsApp que indicam a venda de drogas, como "acabou a droga já? E aí pai, cê vai demorar? Senão vou lá em Mendonça buscar droga para soltar aqui mano. O bagui tá parado, fi. Todo mundo querendo droga mano, ou. Tem três usuário aqui já ó. Ô fião, desde manhã eu to falando pu cê que a droga acabou parça. Você tá metendo o louco, Biel, ou. O bagulho tá sem nada aqui, fi, Vem, vem para pro reno" (fls. 172/177).

O laudo do aparelho celular da marca Huawei foi inconclusivo, pois ele estava bloqueado por senha PIN, impossibilitando o acesso aos dados armazenados em sua memória (fls. 198/171). Já a perícia no celular da marca Samsung não identificou arquivos com conteúdo referente ao tráfico de drogas nem comunicações através de aplicativos ou informações de geolocalização (fls. 178/181).

A testemunha Investigador de Polícia Sérgio Nunes Pombo Filho relatou que o Setor de Inteligência da Polícia Civil fez investigações e apurou que havia alguns pontos de tráfico na cidade de Adolfo. Declarou que, com base em tais investigações, fora expedido mandado de busca e apreensão para alguns endereços e que o endereço de

Cristiano foi o segundo local diligenciado. Afirmou que na residência de Cristiano havia duas casas, a da frente que era ocupada por ele e a do fundo ocupada por seu genitor, que na época dos fatos ainda era vivo. Por ter uma saúde precária, o pai de Cristiano quase não era encontrado em sua residência, que acabava então sendo usada por Cristiano, Tyrone e Gabriel. As buscas foram realizadas simultaneamente nas duas casas. Na casa em que Cristiano estava foram encontradas 37 porções de crack pelos policiais militares; após chegar lá, juntamente com o Delegado de Polícia, afirmou que procederam a uma busca completa e encontraram na casa da frente mais 21 porções de crack. Nas imagens que foram realizadas durante as gravações no local Cristiano é visto constantemente, às vezes vendendo entorpecente e às vezes fazendo a proteção do local onde eram comercializadas as substâncias entorpecentes. Declarou que Cristiano foi preso na diligência de busca e solto na audiência de custódia e que, no mesmo dia da soltura, à noite, foi visto no local comercializando drogas. Declarou que houve a expedição de novo mandado de busca e apreensão que restou positivo para a apreensão de substância que posteriormente foi identificada como crack e que Cristiano foi preso preventivamente. Declarou que em imagens capturadas por uma câmera instalada pela Prefeitura Municipal no local não se detectou mais a presença de usuários de entorpecentes. Afirmou que houve uma ocorrência em que o Cristiano agrediu o indivíduo de prenome Carlos com um facão, na região da cabeça, por dívidas ligadas ao uso de entorpecentes. Declarou que, no dia em que Cristiano foi preso, tanto na primeira como na segunda vez, havia dois adolescentes na residência, um de nome Gabriel e outro de nome Tyrone, que, depois da prisão de Cristiano, encontraram outro local para o de tráfico de entorpecentes. Declarou, que quando abordados, os adolescentes alegaram que eram usuários, mas que essa era uma desculpa esdrúxula pela quantidade de entorpecentes encontrada com eles. Aos questionamentos feitos pela Promotora de Justiça respondeu que foram feitas diversas denúncias de tráfico de entorpecentes na residência de Cristiano; que em uma câmera instalada e que dava imagens da frente da casa de Cristiano, foram feitas mais de 200 gravações que denotavam que naquele local era praticado o tráfico de entorpecentes. Declarou que, com relação aos valores em espécie encontrados com os adolescentes, estes, quando indagados, apresentavam desculpas evasivas e divergentes e que eles não comprovaram a origem lícita do dinheiro. A testemunha PM José Renato Cabral narrou que estava em diligência cumprindo mandado de busca e apreensão e foi até a casa de Cristiano, que, ao ser abordado, questionou o motivo de os policiais estarem em sua casa. Declarou que com a exibição do mandado, Cristiano permitiu a entrada na residência para que fossem efetuadas as buscas, e inicialmente nada foi encontrado. Quando questionaram se havia outras pessoas na residência ou drogas, Cristiano respondeu que não havia drogas mas que havia mais duas pessoas em um outro quarto da residência. Em diligência nesse quarto, foram abordados e revistados Gabriel e Tyrone. Com Gabriel havia R\$ 60,00 em notas diversas, e com Tyrone, R\$ 707,45 em notas e moedas. Indagados, ambos questionaram que não sabiam nada sobre drogas. Na revista em continuação, fora feita varredura em um sofá em que estava Cristiano, onde foi encontrado um pote contendo 37 porções de crack. No quarto em que estavam Gabriel e Tyrone foram encontradas 184 porções de uma substância aparentando ser crack. Indagados, ambos disseram que aquela droga encontrada era a única droga em seu poder. Para assegurar a segurança e a integridade física de todos os presentes, os três envolvidos foram algemados. Na sequência, chegou ao local o Investigador de Polícia Sérgio, que fez busca no imóvel que fica na frente desta residência e encontrou mais 21 porções de crack. Então foi dada voz de prisão aos elementos, que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Adolfo. Com relação aos adolescentes envolvidos na ocorrência, afirmou que são de José Bonifácio e que já eram conhecidos nos meios policiais por ligação com o tráfico de entorpecentes, tanto como traficantes quanto como usuários.

A testemunha Gabriel dos Santos Matos disse que não é parente de Cristiano. Estava no local dos fatos, quando foram surpreendidos por policiais militares enquanto dormiam, os quais apreenderam a droga que estava em sua posse. Disse que atualmente está com 17 anos de idade e que não sabe se foi processado por esta ocorrência junto à Infância e Juventude. Afirmou não ter sido ouvido em outra audiência sobre

o mesmo caso. Aos questionamentos feitos pela Promotora de Justiça, respondeu que não morava na casa de Cristiano, que estava lá somente por algumas horas para descansar e que nesse tempo foi abordado pela Polícia Militar. Afirmou que as drogas apreendidas no quarto onde estava com Tyrone eram suas, por ser usuário de entorpecentes. Declarou que fez uso de entorpecentes na casa de Cristiano, mas que este não sabia que havia mais drogas.

Houve desistência da testemunha Tyrone Henrique Santos.

Em seu interrogatório, o acusado confessou a acusação, afirmando que é usuário de entorpecentes e costumava manter em sua residência grande quantidade de drogas. Declarou que os adolescentes pediram para dormir na casa e que, em abordagem policial, as drogas foram encontradas. Acredita que os adolescentes disseram que as drogas eram deles por terem ficado com medo, mas na verdade toda a droga era sua. Afirmou que os adolescentes são apenas usuários, que não possuem qualquer ligação com a droga encontrada e que na sua residência os adolescentes Gabriel e Tyrone nunca fizeram uso de entorpecentes, tendo ido lá somente para dormir. Declarou que além de ser usuário já praticou também o comércio de entorpecentes para poder sustentar financeiramente o seu vício.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Os policiais dirigiram-se ao local dos fatos a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente ao Proc. 1500584-79.2022.8.26.0306 (fls. 34/35), uma vez que já havia fundada suspeita de tráfico de drogas na residência do acusado, com movimentações em sua casa após as 22h, inclusive com entrada e saída de pessoas conhecidas por serem usuários de drogas.

Ao chegar ao local, foram recepcionados pelo acusado, que autorizou o ingresso em sua residência. Em revista na casa, foram localizadas 37 porções de crack em um pote que estava com o réu no sofá. Além disso, no quarto onde estavam os adolescentes Gabriel e Tyrone, foram encontradas 184 porções de crack e 01 porção de maconha, além de dinheiro, em nota e moedas diversas, com os adolescentes. Por fim, na frente do imóvel ainda foram encontradas mais 21 porções de crack.

Pela quantidade, variedade e modo de acondicionamento das drogas e pelos locais onde foram encontradas não é possível afirmar de plano que elas se destinavam a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06).

Ressalte-se que o modo e a variedade de acondicionamento e a expressiva quantidade de drogas e dinheiro encontradas deixaram claro que o réu guardava o entorpecente com o objetivo de vendê-lo para o consumo de terceiros, como descrito na denúncia. Vale dizer que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes (ou terceiras pessoas desconhecidas) pretendessem incriminar o acusado falsamente. Portanto, os testemunhos merecem crédito.

Ressalte-se que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Isso porque o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 caracteriza-se como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali descritas, dentre elas a de trazer drogas consigo, sem autorização, como descrito na denúncia.

Desse modo, a dinâmica dos fatos descrita na denúncia deve prevalecer, estando bem

claro que o acusado estava traficando e que o numerário apreendido foi auferido em razão da venda de drogas.

Também restou bem demonstrado que a prática do tráfico cometida pelo acusado envolvia e atingia os adolescentes Gabriel e Tyrone, que estavam no local dos fatos, cercados de entorpecentes e portando elevada quantia em dinheiro.

Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do delito.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores “natureza e quantidade de drogas apreendidas” para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas,

supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n.

666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenação transitada em julgado para a Defesa em 20/03/2019 (data do fato: 30/03/2015), com extinção da pena em 20/08/2021 (fls. 182/185).

A condenação mencionada deve ser utilizada para caracterizar a reincidência, que é circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Quanto às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, relevante para a formação da condenação judicial (Súmula 545 do STJ). Presente também a agravante da reincidência, pelo antecedente mencionado. Logo, a reincidência deve ser compensada com a confissão, como prevalece na jurisprudência: 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (AgRg no HC 625.076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação. (HC 480.489/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019)

A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes. (HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Consequentemente, a pena não se altera.

A reincidência afasta a caracterização o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que a prática do tráfico envolveu adolescentes. Consequentemente, a pena deve ser aumentada de 1/6 a 2/3.

No caso, a pena deve ser aumentada de 1/6, o que resulta em: 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Logo, torno definitiva a pena em: 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente

até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Deixo de considerar o tempo de prisão preventiva para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por entender que tal avaliação compete ao juízo da execução criminal, haja vista que para a progressão de regime é necessária a presença da boa conduta carcerária (art. 112, §1º, da Lei 7.210/84), requisito subjetivo que, por isonomia, deve ser exigido de todos, sentenciados e presos provisórios (art. 387, §2º, do CPP).

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena, uma vez que, embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a pena é superior a 4 anos e o acusado é reincidente, de modo que a concessão dos benefícios não seria suficiente ou socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar CRISTIANO MARQUES DE LIMA à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c. art.40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Como efeito da condenação, imponho a perda dos bens e valores apreendidos (arts. 5º, LIV, e 243, parágrafo único, da Constituição e art. 91 do CP). Os bens poderão ser destinados à conservação e utilização, se houver interesse público, ou à alienação, enquanto o produto da arrematação e valores apreendidos deverão ser mantidos em depósito até o trânsito em julgado (arts. 61 a 63 da Lei 11.343/06). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico. Serve a presente como ofício.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo preso preventivamente após ser surpreendido em flagrante e a necessidade de custódia cautelar permanece em virtude da gravidade concreta da conduta, devido à reincidência, à expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas, e à caracterização do tráfico como meio de vida e de sustento do uso de drogas, contexto que evidencia que a prisão é necessária para evitar a reiteração da prática delitiva, mostrando-se ineficaz medida cautelar diversa, inclusive pela possibilidade de prática de tráfico em domicílio (arts. 282, §6º, e 312 do CPP).

Por tais motivos, recomende-se o acusado à prisão em que se encontra (art. 387, §2º, do CPP). Serve a presente como ofício.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ) e a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ); bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspense" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

José Bonifacio, 18 de outubro de 2022.